

1500480-06.2021.8.26.0312

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DE OLIVEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

FLAVIO FURTADO ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 26 de novembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá - SP - cep 11800-000

1500480-06.2021.8.26.0312 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500480-06.2021.8.26.0312

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DE OLIVEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

FLAVIO FURTADO ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 26 de novembro de 2021, por volta de 00h30min, na Rua Kengo Kurita, 308, Jardim Juquiá, nesta cidade e comarca de Juquiá, trazia consigo, para fins de tráfico, comércio e fornecimento a terceiros, 72 microtubos de cocaína, com peso aproximado de 91,22g; 112 invólucros contendo Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 322,43g; e 70 pedras de crack, com peso aproximado de 31,92g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi autuado em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva

(fls. 40/43).

Recebida a denúncia (fls. 64), o acusado foi notificado (fls. 108) e apresentou resposta à acusação (fls. 116/125).

O denunciado foi regularmente citado (fls. 165).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de três testemunhas e o réu foi interrogado.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, pretendendo subsidiariamente a fixação de penas no mínimo, com máxima redução, em regime brando, com detração da prisão provisória, com substituição por restritiva de direito, sendo facultado recurso em liberdade. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Não há matérias preliminares a serem apreciadas, nem prejudiciais de mérito. Não se vislumbra nulidades, tampouco hipótese de prescrição.

Passo, então, a apreciar o mérito.

A ação penal é improcedente.

Eis a síntese da prova oral produzida.

O policial militar FABRICIO SOUZA SILVA relatou em Juízo que em diligência no local, visualizaram o réu e outras duas pessoas. Com o Rafael e com o Joel, encontraram drogas condizentes com o uso e eles afirmaram que haviam comprado com o réu. O réu foi abordado após uma breve fuga, tendo dispensado uma sacola. Não se lembra se ele deu alguma explicação. Não se recorda se apreenderam quantia em dinheiro ou qualquer outra coisa. Quando chegaram no local, o réu já largou a sacola. No máximo 5 metros depois ele foi detido. A iluminação no local é normal. O policial militar EDNEI MUNIZ DE OLIVEIRA descreveu em Juízo que estavam em patrulhamento no local, já conhecido pelo tráfico de drogas. Um transeunte, não se lembra quem, informou que havia grande movimento de venda de drogas. Avistaram dois indivíduos no começo do "escadão". Conseguiu abordar duas pessoas, o Joel e o Rafael. Um terceiro indivíduo, o Flávio, ora réu, se evadiu. O outro policial foi atrás dele e o abordou. Com o réu foram apreendidos os entorpecentes. Com os demais indivíduos, também encontraram um pouco de droga, característica de usuários. O réu não dizia nada, apenas falava que não era dele a droga, mas foi possível vê-lo dispensando a sacola. Os demais indivíduos diziam que compraram as drogas do réu. A rua era um pouco escura, não muito clara. O réu dispensou uma sacola preta, cerca de 5 ou 10 metros antes do local em que o réu foi detido. Ele só percebeu a presença da viatura quando já estava muito próxima. Não se lembra se houve apreensão de dinheiro com o réu. Não encontraram mais nada com ele, apenas o entorpecente.

A testemunha JOEL DA SILVA contou em Juízo que não conhece o réu. Estava no terceiro degrau do "escadão", sentado, quando foi abordado pelos policiais. Tinha ido na casa de sua tia, mas ela não estava. Ficou esperando. Não estava com o réu. Foi abordado pelo policial, que apontou uma arma em seu rosto. Foi algemado, colocado no chão e depois conduzido à delegacia. Não viu os policiais abordando o réu. Estava sozinho no local, sentado no escadão sozinho. Sabe que já houve venda de droga no local mas achou que não estava mais ocorrendo.

O réu, ouvido em Juízo, afirmou que mora lá em cima da escadaria. Tinha ido buscar fraldas para suas filhas na casa de uma amiga de sua mãe, momento em que foi abordado pela polícia. Eles apareceram com uma sacola de drogas e disseram que era sua. Eles determinaram que deitasse no chão, o que foi feito. Depois eles apareceram com as drogas. Eles disseram que ali era ponto de tráfico. Respondeu que mora lá em cima do escadão. Havia só uma menina sentada lá em cima. Só viu o Joel e o Rafael na delegacia. Não conhecia os policiais. A abordagem foi por volta das 21 horas.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não foram produzidas, em Juízo, provas suficientes para embasar a condenação.

Nesse ponto, observo que, em juízo, foram expostas duas teses conflitantes e igualmente verossímeis, que não podem ser descartadas de plano.

A versão acusatória está respaldada pelos depoimentos das testemunhas policiais, responsáveis pela abordagem. Ambas confirmaram, de forma harmônica e coerente, que

o réu estava realizando a venda de entorpecentes no local e tentou se evadir ao ver a equipe policial, dispensando uma sacola contendo drogas.

A versão da defesa, por outro lado, encontra respaldo no depoimento da testemunha Joel e do próprio acusado, bem como naquela dada em sede policial pela testemunha Rafael de Oliveira.

Rafael disse, na fase policial, que "estava andando sozinho pela rua Kengo Kurita quando por volta das 00:30h foi abordado pelos policiais militares que após fazerem revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado consigo. Mesmo assim, foi conduzido pelos policiais até a delegacia de polícia para prestar depoimento".

Joel, por sua vez, apresentou em juízo relato harmônico e condizente com aquele dado na fase policial. Em ambas as oportunidades, afirmou que estava sozinho sentado na escadaria existente no local dos fatos, após ter consumido bebida alcoólica, momento em que foi abordado pela equipe policial. Insistiu que estava sozinho no momento da abordagem e que não viu o réu no local.

O réu, por sua vez, nega os fatos de forma veemente, afirmando que sequer viu as testemunhas Joel e Rafael no local, somente vindo a encontrá-las na Delegacia de Polícia.

É verdade que o depoimento de Joel e Rafael devem ser apreciados com ressalvas, pois ambos foram conduzidos à delegacia para averiguar seus envolvimentos nos fatos. Joel está, ademais, respondendo pela posse de droga para consumo pessoal. Todavia, o depoimento de policiais deve ser igualmente apreciado com cautela pelo magistrado. A nobre função por eles exercida, merecedora de todo o respeito e consideração, envolve diretamente a repressão da criminalidade e, portanto, está em constante tensão com direitos constitucionais, ao mesmo tempo em que busca garanti-los. Disso decorre uma natural propensão de agentes de segurança a justificar a conduta que adotaram no exercício de suas dignas atribuições, ratificando-a em juízo, o que pode resultar na tendência de atribuir ao réu a prática da ação ilícita objeto de apuração. Isso, contudo e evidentemente, não obsta o depoimento de policiais; apenas suscita cuidado em sua valoração.

A esse respeito, é a lição doutrinária:

"É de bom senso e cautela que o magistrado dê valor relativo ao depoimento, pois a autoridade policial, naturalmente, vincula-se ao que produziu investigando o delito, podendo não ter a isenção indispensável para narrar os fatos, sem uma forte dose de interpretação. Outros policiais também podem ser arrolados como testemunhas, o que, como regra, ocorre com os realizadores da prisão em flagrante. Nesse caso, podem narrar importantes fatos, embora não deva o juiz olvidar poderem eles estar emocionalmente vinculados à prisão efetivada, pretendendo validá-la e consolidar o efeito de suas atividades. Cabe, pois, especial atenção para a avaliação da prova e sua força como meio de prova totalmente isento" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2021 - e-book). O C. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar a respeito do valor probatório do depoimento de policiais:

"A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1.ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485.543 - SP, 5.ª T., rel. Felix Fischer, 21.05.2019, v.u.).

Logo, não há qualquer óbice à valoração do depoimento das testemunhas policiais. No caso dos autos, contudo, há uma versão antagônica que também encontra respaldo nos elementos de prova produzidos em juízo.

Note-se que o réu e as testemunhas Joel e Rafael, esta última na fase policial, disseram, sem incorrer em qualquer contradição, que foram abordados sozinhos, o que destoa da dinâmica narrada na denúncia. E o réu, por sua vez, nega de forma veemente que as drogas encontradas fossem suas.

Além disso, segundo os próprios policiais, nenhum ato efetivo de mercancia da droga foi presenciado. Segundo o policial Fabrício, com o Rafael e com o Joel foram

encontradas drogas condizentes com o uso e eles afirmaram que haviam comprado com o réu.

Contudo, Rafael e Joel negaram que tenham adquirido qualquer droga do réu.

Não se está, vale ressaltar, a lançar qualquer suspeita em relação à palavra dos policiais. Ao contrário, como visto acima, a versão acusatória é verossímil e está devidamente respaldada por depoimentos coesos das testemunhas. Entretanto, há também outra versão, a merecer igual consideração, porque nada nos autos permite afastá-la de forma segura.

Em suma, o quadro probatório constante nos autos permite duas conclusões, uma no sentido da hipótese acusatória, outra em adoção da tese defensiva.

Se é verdade que o depoimento dos policiais não pode ser descartado como meio de prova, também é verdade que essa prova não tem qualquer prevalência em relação às demais. Enfim, para a prolação de uma decisão condenatória, todo o acervo probatório deve ser considerado e valorado, a fim de que seja possível atingir conclusão firme e segura, descartando-se qualquer outra.

Em outras palavras, a prolação de decreto condenatório pressupõe a existência de prova inequívoca da materialidade e da autoria do delito que motivou a instauração do processo penal. Prova, no direito brasileiro, é aquela produzida em contraditório judicial, razão pela qual, a teor do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se aplica analogamente ao caso em tela: "Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos" (AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal assegura a todo cidadão que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mais adiante, o inciso LVII estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Da mesma forma dispõe o art. 8º, 2, do Pacto de San José da Costa Rica, incorporado pelo Decreto 678/92, que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

Não resta dúvida de que o exercício da jurisdição penal deve observar o devido processo legal substantivo. Cabe ao Poder Judiciário, após a instrução do feito, analisar se as provas produzidas são bastantes para fundamentar a privação da liberdade do réu. Tal atividade probante, cujo resultado poderá infirmar a presunção de inocência do sujeito, deverá ser feita perante um Poder imparcial e equidistante, constitucionalmente destinado a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Persistindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos mesmo após a instrução, não se atinge o padrão ("standard") probatório exigido para ensejar uma condenação.

"Somente havendo prova robusta, forte, altamente confiável, de indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de verossimilhança, de probabilidade (ou certeza, para quem admite essa categoria na perspectiva processual), que supere toda e qualquer dúvida fundada sobre questões relevantes do caso penal, é que autoriza uma sentença penal condenatória, pois é apta a superar a

barreira do "acima da dúvida razoável" e consegue dar conta do nível de exigência da garantia da presunção de inocência" (Junior, Aury Celso Lima L. DIREITO PROCESSUAL PENAL. Editora Saraiva, 2021 - e-book). Nesse caso, aplica-se a máxima segundo a qual a dúvida favorece o réu, em decorrência da presunção de inocência. A propósito, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça:

1-) Apelação criminal. Furto tentado. Sentença absolutória. Inconformismo da Acusação. 2-) Materialidade duvidosa. As provas colhidas nos autos deixam dúvida acerca da dinâmica do ocorrido e do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado, sendo que a dúvida deve favorecer o réu. Para proferir-se uma condenação criminal é preciso que haja prova escorreita e segura da existência do fato delituoso e de sua autoria para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida. E no caso em estudo, isso não ocorreu. 3-) Não provimento do recurso do Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1518063-96.2020.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020).

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia. Dada a solução de mérito adotada, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a destruição das drogas apreendidas, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado:

a) não reclamada a restituição do aparelho celular apreendido em até 90 dias seguintes ao trânsito em julgado por quem comprove documentalmente regular aquisição, oficie-se para sua destruição;

b) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º)

Intimem-se. Comunique-se.

Juquía, 08 de setembro de 2022.